

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 968/2536 บริษัท เปปซี่โค อินค์ จำกัด โจทก์
บริษัท ฟรีด้อมฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำเลย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 9, มาตรา 41 (1)

บริษัทฟ.เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า FRITOS จดทะเบียนไว้ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2476 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนี้ใน
ประเทศไทย เมื่อปี 2524 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ออกคู่มือรับจด
ทะเบียนให้โจทก์ในปี 2525 ต่อมาปี 2530 บริษัทฟ. ได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้
โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ทั่ว
โลกแสดงว่า บริษัทฟ. ได้ให้สัตยาบันการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
แล้ว โจทก์จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยมีอำนาจฟ้องผู้
เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ เครื่องหมายการค้าคำว่า FREEDOS ของ
จำเลยและเครื่องหมายการค้าคำว่า FRITOS ของโจทก์ ต่างก็เป็นคำอักษรโรมัน
อ่านออกเสียงสองพยางค์เหมือนกัน แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลย จะมีรูป
ประดิษฐ์เป็นตัวอักษร F สองตัว หันหลังชนกันในกรอบสี่เหลี่ยมและมีภาษาไทย
กำกับว่า ฟรีโดส์ แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำน่าจะมีสาระสำคัญอยู่ที่การอ่านออก
เสียง หรือสำเนียงเรียกขานมากกว่าอย่างอื่น เครื่องหมายการค้าของจำเลยอ่านว่า
ฟรีโดส์ มีสำเนียงใกล้เคียง หรือเกือบเหมือนกับเสียงอ่านเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์คือคำว่า ฟรีโดส์หรือฟรีโดส์ อีกทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วย
ตัวอักษรโรมัน 6 ตัว ส่วนของจำเลยมี 7 ตัว แต่ปรากฏว่ามีซ้ำกันถึง 4 ตัว จึงถือได้
ว่าเครื่องหมายการค้า คำว่า FREEDOS ของจำเลยมีลักษณะตัวอักษรและการอ่าน

ออกเสียง เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า คำว่า FRITOS ของโจทก์ โจทก์ จึงมีสิทธิดีกว่าจำเลย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้มอบอำนาจให้นายธเนศ เปเรราฟ้องคดีแทน โจทก์เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า FRITOS อ่านว่า ไพรทอส ฟรีโดส์ หรือฟรีโดส์ แปลไม่ได้ เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก อาหารว่างสำเร็จรูป เช่น ข้าวโพดแผ่น จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกเมื่อปี 2476 และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และต่อมาได้ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวในประเทศไทย ตามภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 3 และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน ให้ตามเอกสารหมายเลข 4 ต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยลอกเลียนแบบ เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า FREEDOS อ่านว่า ฟรีโดส์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529 ในจำพวกสินค้าประเภท เดียวกับโจทก์ โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ยกคำ คัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลย เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันอาจทำให้สาธารณชนผู้ซื้อ สับสนหลงผิดโดยเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วน ร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ซึ่งทำให้โจทก์เสียหาย ขาดประโยชน์ในทางทำมาหาได้ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นรายเดือนเดือนละ 50,000 บาท ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มี สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า FRITOS ดีกว่าจำเลย และขอให้จำเลยเพิกถอน

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า FREEDOS หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้
ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและสั่งห้ามมิให้จำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยและให้จำเลยทำลาย
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งปรากฏบนสินค้าจำเลยให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็น
รายเดือนเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยให้การว่า ไม่รับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์และการมอบอำนาจให้
นายธเนศ เปเรร่า ทำการต่าง ๆ แทนโจทก์ โจทก์มิได้เป็นเจ้าของรูปประดิษฐ์
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าFRITOS อ่านไฟรทอส และได้ใช้กับสินค้าอาหาร
ว่างสำเร็จรูปซึ่งผลิตจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและ
สินค้าของโจทก์ก็ไม่ได้มีการโฆษณาและจำหน่ายโดยแพร่หลายแต่อย่างใด จำเลย
มิได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าคำว่าFRITOS อ่านว่า ไฟรทอส ตามที่โจทก์
กล่าวอ้าง โจทก์ไม่เคยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจำหน่ายในท้อง
ตลาดเพียงแต่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้เพื่อขัดสิทธิของผู้อื่นเท่านั้นนอกจากนี้รูป
ลักษณะของเครื่องหมายการค้าคำว่า FRITOS กับคำว่าFREEDOS แตกต่างอย่าง
เห็นได้ชัด และยังมีสำเนียงเรียกขานต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์อย่างออกเสียงว่าไฟรทอส ส่วนของจำเลยอ่านออกเสียงว่า ฟรีโดส์ จึงไม่
อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดสับสนในเครื่องหมายการค้าทั้งสองได้ดังที่โจทก์กล่าว
อ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลย

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.10แผ่นที่ 4 ซึ่งบริษัท
ฟรีโต-เลย์ อินค์ มอบอำนาจให้บริษัทโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า
FRITOS ลงวันที่ 1 กรกฎาคม2530 แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2530

จึงถือว่าขณะโจทก์ฟ้องคดีนี้ โจทก์ยังมิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า บริษัทโจทก์เป็นเครือเดียวกับบริษัทฟรีโต-เลย์ อิงค์ โจทก์มีอำนาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า FRITOS ในประเทศไทยได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเครื่องหมายการค้า คำว่า FREEDOS ของจำเลยมีลักษณะเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้า คำว่า FRITOS ของโจทก์ โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย แต่ไม่สมควรกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ พิพากษากลับให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าFRITOS ตามคำขอเลขที่ 118737 ดีกว่าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 155174ให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FREEDOSตามคำขอเลขที่ 155174 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อแรกจำเลยฎีกาว่าบริษัทฟรีโต-เลย์-อิงค์ ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่าFRITOS ได้มอบอำนาจให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวภายหลังโจทก์ได้ฟ้องคดีนี้แล้ว ดังนั้นในขณะที่ยื่นฟ้อง โจทก์จึงยังมิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พยานหลักฐานโจทก์ได้ความว่า บริษัทฟรีโต-เลย์ อิงค์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า FRITOS จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2476 ตามเอกสารหมาย จ.9 บริษัทดังกล่าวเป็นเครือเดียวกับบริษัทโจทก์ โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย เมื่อปี 2524นายทะเบียน

เครื่องหมายการค้าได้ออกหนังสือคู่มือจดทะเบียนให้โจทก์ เมื่อปี 2525 ตาม
เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ต่อมาเมื่อปี 2530 บริษัทดังกล่าวได้ทำหนังสือมอบ
ฉันทะให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ในประเทศไทย และ
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกตามเอกสารหมาย จ.10 เห็นว่า ตามมาตรา 9 แห่งพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 บัญญัติว่า ถ้าผู้ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องมีหนังสือมอบฉันทะแสดง
ว่าผู้ขอมีอำนาจจดทะเบียนได้แนบมากับคำขอด้วย การที่บริษัทฟรีโด-เลย์ อิงค์ ได้
ทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในภายหลัง
แสดงว่าบริษัทดังกล่าวได้ให้สัตยาบันการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
แล้ว โจทก์จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยมีอำนาจฟ้องผู้
เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ประการต่อไปจำเลยฎีกาว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า FREEDOS ของจำเลย
ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า คำว่า FRITOS ของโจทก์ และสำเนียง
เรียกขานในภาษาไทยก็แตกต่างกัน ศาลฎีกาเห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำ
ต่างก็เป็นคำในอักษรโรมันอ่านออกเสียงเป็น 2 พยางค์ เหมือนกันคือ FREE กับ
FRI พยางค์หนึ่ง และ DOS กับ TOS อีกพยางค์หนึ่ง แม้เครื่องหมายการค้าของ
จำเลย จะมีรูปประดิษฐ์เป็นตัวอักษร F สองตัว หันหลังชนกันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
และมีคำภาษาไทยกำกับว่า ฟรีโดส์ แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำน่าจะมีสาระ
สำคัญอยู่ที่การอ่านออกเสียงหรือสำเนียงเรียกขานมากกว่าอย่างอื่นเกี่ยวกับการอ่าน
ออกเสียงคำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์มีนายเลสเตอร์ ลอยด์ นาคเลย์
ลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สัญชาติอเมริกันกับนางสาววรรณช
เชียงพุดชา ลูกจ้างโจทก์เบิกความว่า คำว่าFRITOS นี้ คนอเมริกันจะอ่านออกเสียง
ว่า ฟรีโดส์ หรือ ฟรีโดส์และได้ความจากนางจริยา เปรมปราณีรัชต์ ลูกจ้างโจทก์ว่า
บริษัทโจทก์ในต่างประเทศเคยส่งวีดีโอเทปการออกเสียงคำดังกล่าวในการโฆษณา

สินค้านั้นมาให้ดู โดยอ่านว่า ฟรีโดส หรือ ฟรีโตส ในชั้นนายทะเบียนวินิจฉัยคำ
คัดค้านและคำโต้แย้งของโจทก์จำเลยโจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า คำว่า FRITOS ของ
โจทก์ อาจอ่านออกเสียงว่า ฟรีโตส หรือ ฟรีตอส หรือ ไฟรีโตส หรือ ไฟรีทอสตาม
เอกสารหมายเลข 4 (แผ่นที่ 1) ส่วนจำเลยยื่นคำโต้แย้งว่าคำว่า FREEDOS ของ
จำเลยว่าออกเสียงว่า ฟรีโดส แต่คำว่าFRITOS ของโจทก์สามารถอ่านออกเสียงได้ว่า
ฟรีโตส หรือฟรีตอส หรือ ไฟรีโตส หรือ ไฟรีทอส ตามเอกสารหมายเลข 4(แผ่นที่ 2) ดัง
นั้นเมื่อพิจารณาตามคำคัดค้านและคำโต้แย้งของโจทก์จำเลยประกอบกับคำเบิกความ
ของพยานโจทก์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า FREEDOS ของ
จำเลยซึ่งอ่านว่าฟรีโดส นั้น มีสำเนียงใกล้เคียงหรือเกือบเหมือนกับเสียงอ่าน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า ฟรีโดส หรือฟรีโตสเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 6 ตัว ส่วนของจำเลยมี 7 ตัว แต่ซ้ำกันถึง 4 ตัว
คือ F.R.O และ S ตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายกับตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนการอ่านออกเสียงนั้นแม้คำ
ของโจทก์จะสามารถอ่านออกเสียงได้หลายอย่าง ส่วนคำของจำเลยอ่านออกเสียงได้
อย่างเดียวแต่ก็มีเสียงเกือบเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์คือคำว่า ฟรีโดสของจำเลย
กับ คำว่า ฟรีโตส หรือ ฟรีโตสของโจทก์ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือได้ว่า
เครื่องหมายการค้าคำว่า FREEDOS ของจำเลย มีลักษณะตัวอักษรและการอ่านออก
เสียงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า TRITOS ของโจทก์ โจทก์จึงมี
สิทธิดีกว่าจำเลย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-เรีงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ประการสำคัญ ในการที่จะชี้ว่า สินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
ผู้ผลิตรายอื่น อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือตัวผู้ผลิตสินค้า และ
คุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น การที่จะให้เครื่องหมายการค้าได้ทำ
หน้าที่ดังกล่าวได้สมบูรณ์ เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าต่าง ๆ หรือต่างเจ้าของกัน
ต้องแตกต่างกัน กล่าวคือ ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน
หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น การ
พิจารณาในประเด็นเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้านี้มีการ
พิจารณาทั้งในชั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
และศาล แต่ก็ไม่ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องความเหมือนหรือ
คล้ายของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างใด การพิจารณาทำหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้จึง
ต้องอาศัยแนวคำพิพากษาศาลฎีกา แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า ตลอดจนแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศเข้าด้วย
กัน การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าหากจะมุ่งถึงตัว
เครื่องหมายการค้าเอง (Themarkspere) เราสามารถแบ่งลักษณะของ
เครื่องหมายการค้าออกได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1. เครื่องหมายคำ 2. เครื่องหมาย
รูป 3. เครื่องหมายคำและรูป เครื่องหมายคำ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคำดัง
กล่าวเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ จะดูจากสำนวนตัวอักษรของแต่ละเครื่องหมายว่า
มีกี่ตัวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่เหมือนกันจำนวนกี่ตัว เสียงอ่านของ

เครื่องหมายค่านั้นเป็นอย่างไร ลักษณะการวางตัวอักษร หรือตัวอักษรประดิษฐ์เหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ ตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกัน เช่น เครื่องหมายคำว่า MISTERMINIT กับ MINIT(9/2527) เครื่องหมายคำว่า ACOLATE กับ AMCOLATE(43/2528) เครื่องหมายคำว่า Audix กับ AUNIX(26/2530) เครื่องหมายคำว่า แฮร์ซิลค์ กับ AIRSILK(327/2530) เครื่องหมายคำว่า โซลาเติกซ์ กับ ZOLATREK(22/2529) ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกัน เช่น เครื่องหมายคำว่า PHENERGAN กับ PHENAGIN(ฏ.779/2506) เครื่องหมายคำว่า DEQUADIN กับ DEORADIN(ฏ.1779/2514) เครื่องหมายคำว่า GANTRISIN กับ KANDICIN(ฏ.1360/2516) เครื่องหมายคำว่า RICOPY กับ RECOPY(ฏ.1748/2524) เครื่องหมายคำว่า VIXOL กับ Vitol(ฏ.2636/2529) เครื่องหมายคำว่า DIMETAPP กับ MEDITAPP(ฏ.3692/2534) เครื่องหมายรูป เราจะต้องดูว่าเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเด่นที่จุดใด ลักษณะเด่นนั้นเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ หรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ที่จุดใด คำวินิจฉัยที่ 122/2529 เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนและของผู้คัดค้าน ต่างมีรูปนกเพนกวิน เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกัน แม้การประดิษฐ์รูปลักษณะของนกจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เนื่องจากเครื่องหมายทั้งสองเป็นเครื่องหมายรูปอย่างเดียวกันไม่มีคำกำกับ จึงย่อมเรียกขานได้เหมือนกันว่าตรานกเพนกวิน เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 645/2507 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปเครื่องหมายตรา "คนขี่ควาย" ส่วนสินค้าของจำเลยใช้เครื่องหมายตรา "ลิงขี่ควาย" แต่เมื่อมองดูแล้วจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดย

เฉพาะควายมีหัว เขา ลำตัว หาง และเท้าเดินเหมือนคล้ายเกือบจะเป็นควายตัวเดียวกัน คงแตกต่างเฉพาะลึงกับคนซึ่งอยู่บนหลังควายแต่ขนาดลักษณะท่าทางของลึงและคนคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งบุคคลธรรมดาอาจหลงเข้าใจผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ได้

นอกจากนี้สามารถศึกษาแนวการวินิจฉัยของศาลฎีกาได้จากฎีกาที่ 350/2509, ฎีกาที่ 562/2510, ฎีกาที่ 1151/2511, ฎีกาที่ 593/2513, ฎีกาที่ 947/2513, ฎีกาที่ 2642/2523, ฎีกาที่ 1419/2524, ฎีกาที่ 1742/2527, ฎีกาที่ 1138/2529, ฎีกาที่ 2198/2532 เครื่องหมายคำและรูป กรณีเครื่องหมายของบุคคลหนึ่งเป็นเครื่องหมายคำ ส่วนของอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเครื่องหมายรูป การที่จะดูว่าเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ จะดูจากเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือ ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า นั้น มีทั้งคำและรูปประกอบอยู่ด้วยกัน การพิจารณาความเหมือนและคล้ายของเครื่องหมายการค้า จะดูจากส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายหรือชื่อเรียกขานของเครื่องหมายนั้น คำวินิจฉัยที่ 495/2531 แม้เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์จะเป็นเครื่องหมายคำว่า "กวาง" ส่วนเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้วจะเป็นเครื่องหมายรูปกวางอยู่ในวงกลมสองชั้น ซึ่งรูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองจะแตกต่างกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายทั้งสองก็เรียกขานได้ว่า ตรากวาง เหมือนกันเมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการครอบคลุมถึงกัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิด ย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1138/2529 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปหัวและคอม้าลาย และคำว่า หัวม้าลายกับอักษรโรมันว่า HEADZEBRA ส่วนของจำเลยเป็นรูปม้าลายยืนทั้งตัวอยู่ในวงกลมและคำว่าตราม้าลาย กับอักษรโรมันว่า ZEBRABRAND สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลย คือรูปม้าลายประชาชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกว่าตราม้าลาย เมื่อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันจะทำให้เกิดสับสน และหลงผิดในแหล่งผลิตได้ อันนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน

จำเลยไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนการค้า สำหรับสินค้าจำพวกที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้
ระดับที่ใช้ในการพิจารณาความเหมือนคล้าย ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของ
เครื่องหมายการค้าจะนำระดับความรู้สึกนึกคิดของนายทะเบียน คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าหรือผู้พิพากษาไปวัดไม่ได้ผู้พิจารณาต้องใช้ระดับความรู้ ความ
เข้าใจของวิญญูชนเป็นระดับในการพิจารณา ส่วนช่วงเวลาที่ต้องคำนึงถึงคือในการ
เลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคไม่มีโอกาสที่จะนำสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ มา
เปรียบเทียบกัน คงต้องพิจารณาว่าหากเห็นสินค้าในช่วงเวลาต่างกันแล้ว

(ฎ.677/2532) จะเกิดการสับสนหรือไม่ ความเคร่งครัดในการพิจารณาจะมีมากยิ่งขึ้น
หากว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้กับสินค้าจำพวกยาอันตราย ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณชน ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ต้องนำ
มาใช้ประกอบในการพิจารณา 1. กลุ่มผู้ใช้สินค้าและราคาสินค้า หากว่าผู้ใช้สินค้าเป็น
ประชาชนทั่วไป อย่างเช่น สินค้าประเภท ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ที่มีราคาธรรมดา
หากใช้เครื่องหมายการค้าเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว ประชาชนจะจดจำเฉพาะเสียง
เรียกขาน ไม่ค่อยใช้ความระมัดระวังสังเกตว่าตัวสะกด คำที่นำมาใช้เป็น
เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นอย่างไร(คำวินิจฉัยที่ 215/2528) ส่วนที่เกี่ยวกับราคา
สินค้านั้น หากว่าสินค้ามีราคาแพง ผู้ซื้อจะพิถีพิถันมากยิ่งขึ้น ระดับที่ใช้ในการ
พิจารณา ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า ต้องคำนึงถึงความ
ระมัดระวังที่ผู้ซื้อพึงจะมีด้วย (คำวินิจฉัยที่ 202/2529) โอกาสที่จะเกิดการสับสน
หลงผิดย่อมเกิดขึ้นได้ยาก 2. จำพวกของสินค้า ดูว่า เป็นสินค้าจำพวกหรือชนิด
เดียวกันหรือไม่ หากว่าเป็นสินค้าจำพวกหรือชนิดเดียวกันจะก่อให้เกิดการสับสนหลง
ผิดได้ง่าย แต่ถ้าหากเป็นสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกันโอกาสที่จะเกิดการสับสน
หลงผิดนั้นเกิดขึ้นได้ยากขึ้นเว้นแต่เครื่องหมายการค้าของเจ้าของรายหนึ่งรายใดนั้น
จะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปแล้ว 3. ความไม่สุจริตของจำเลย ในการที่จะเลียน
แบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น จำเลยเคยเป็นตัวแทน หรือทำงานใน

บริษัท ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อน

(ฎ.137/2534)หรือเคยทำงานหรือถือหุ้นในบริษัทของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาก่อน(ฎ.1748/2524) แล้วมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อลอกเลียนแบบ ในการพิจารณาว่า จำเลยได้กระทำการโดยสุจริตหรือไม่ อาจพิจารณาจากใบสลาก การวางรูปลักษณะ หลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ เป็นต้น หลักประการสำคัญในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า จะต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน

(ฎ.5134/2531,2189/2532) จึงจะสามารถทำให้การใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนนี้เป็นไปโดยสมบูรณ์ และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวนี้ เอื้อนขุนแก้ว